

第37問

甲が自宅付近の夜道を歩いていると、突然、以前から不和であった乙が金属バットを振り上げて襲いかかってきた。甲はとっさに身をかわしたが、乙が執拗に甲を殴打しようとするため、甲は乙の攻撃を避けようとして同人の胸を両手で強く押したところ、乙はそのまま転倒し、後頭部を路上に強く打ち付けて動かなくなった（これを「第1暴行」という。）。甲は、乙が転倒して動かなくなったことを認識したが、同人から理不尽な攻撃を受けたことに対する反感から、「お前、俺をなめているのか」などと怒鳴りながら、乙の頭部を多数回、足蹴にしたり、強く踏みつけるなどの暴行を加えた（これを「第2暴行」という。）。

甲は乙が全く動かなくなったことから、同人が死亡したと考えた。乙の上着のポケットからは同人の財布が飛び出しており、その中に現金とキャッシュカード数枚が入っているのが見えた。甲は金策に窮していたため、その財布を奪い取ると、直ちに現場から逃走した。もっとも、乙は甲が逃走した段階では生存しており、甲が逃走していくところを目撃していた丙の通報によって救急病院に搬送されたが、数時間後、乙は頭部の傷害が原因で死亡した。乙の死因となった傷害は甲の第1暴行から生じており、第2暴行は第1暴行によって生じた傷害を悪化させ、乙の死期を早める効果を有していた。

甲の罪責を論じなさい。

（東京大学法科大学院 平成22年度）

第1 乙に対して暴行を加え、乙を死亡させた行為について

1 防衛行為の一体性

甲は乙に対して数度にわたって暴行を加えており、これが下記で検討するように正当防衛(36Ⅰ)(過剰防衛(36Ⅱ))として評価される可能性があるから、行為の個数をどのように解するのか問題となる(【論点】防衛行為の一体性 司H18,H23,H29,予R2,旧H9-1)。

総合 75 頁 論証 22 頁

判例は、防衛行為の一体性を、時間的場所的近接性を前提として、侵害の継続性、防衛意思(動機)の一個性等の要素から判断している。

本問事実関係の下では、防衛行為の一体性を肯定することはできないだろう(最決平20.6.25【百選Ⅰ27】)。

2 構成要件該当性

乙の死因となった傷害は甲の第1暴行から生じているのだから、第1暴行が傷害致死罪の構成要件に該当することは疑いない。一方で、第2暴行は第1暴行によって生じた傷害を悪化させ、乙の死期を早める効果を有していたのだから、これと(も)死との因果関係を認めることはできなくはない。

しかし、これでは死の結果の二重評価になってしまうから、死因を形成した第1暴行に死の結果を帰責するのがよいだろう。

これに対して、死期を早めた第2暴行に死の結果を帰責させるという考え方もあり得る。これは、最決昭53.3.22【百選Ⅰ14】が採用した考え方である。もっとも、この事案は第1暴行が過失行為、第2暴行が故意行為の事案であり、第2暴行が新たな決意に基づくものであった。本問は第2暴行は第1暴行の追撃行為として第1暴行の延長線上に位置づけられるものであるから、同決定の事案とは異なるというべきだろう。

3 正当防衛の成否

以上を前提に検討すると、第1暴行には正当防衛が成立し、第2暴行には正当防衛はおろか過剰防衛すら成立しない。なお、答案上は、第1暴行、第2暴行それぞれに正当防衛の成否を検討してから、防衛行為の一体性を検討するという形でかまわない。

第2 現金とキャッシュカードを窃取した行為について

1 構成要件としては窃盗罪(235)を検討すべきである。

2 もっとも、甲の認識では、乙は既に死亡しており、死体から財物を奪取する意思しか有していないから、故意のレベルで死者の占有が問題となる(【論点】死者の占有 司H29)。

総合 197 頁 論証 83 頁

この点について、判例(最判昭41.4.8【百選Ⅱ29】)は、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが

相当である」と判示している。

この立場によると、甲の認識を基準としても、窃盗罪の故意は認められることになる。

答案構成

第1 乙に対して暴行を加え、乙を死亡させた行為について

1 傷害致死罪（205）の構成要件に該当する



防衛行為の一体性



時間的場所的接着性を前提として、侵害の継続性、防衛の意思等の
事情を踏まえて行為の一個性を判断すべき



あてはめ



2 第1暴行について

傷害致死罪の構成要件に該当する



正当防衛（36 I）の成否



要件検討



正当防衛成立

3 第2暴行について

傷害致死罪の構成要件該当性は認められない



傷害罪（204）の構成要件に該当する



正当防衛不成立



甲には傷害罪が成立する

第2 現金とキャッシュカードを窃取した行為について

1 窃盗罪（235）の客観的構成要件に該当する



強盗罪（236 I）には当たらない



2 故意（38 I）の有無



死者の占有



殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有
を侵害していると評価できる場合には、占有侵奪が認められる



あてはめ



故意あり

- ↓
3 不法領得の意思あり
↓
甲には、窃盗罪が成立する

第3 罪数

甲には傷害罪、窃盗罪が成立し、これらは社会通念上別個の行為であるから、併合罪（45前段）となる

第1 乙に対して暴行を加え、乙を死亡させた行為について

1 甲は乙に対して暴行を加え、その結果、乙は死亡しているから、甲の行為は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた」ものとして、傷害致死罪（205条）の構成要件に該当する。

ここで、甲は数度にわたって暴行を加えているが、これらの行為を一体としてみるべきか、それとも別個の行為とみるべきか。仮に、全体を一個の行為とみた場合には、傷害致死罪について正当防衛・過剰防衛（36条）の成否を、別個の行為とみた場合には、第1暴行、第2暴行それぞれについて、正当防衛・過剰防衛の成否を検討することになる。

人間の行為は、客観面と主観面の統合体であるから、二つの行為が客観的にみても主観的にみても関連性が強い場合には、行為の一体性を肯定すべきである。すなわち、各行為が時間的場所的接着性を有することを前提として、侵害の継続性、防衛の意思等の事情を踏まえて行為の一個性を判断すべきである。

本件では、確かに、第1暴行と第2暴行は時間的場所的に接着していると思われるが、第2暴行の時点では乙は気を失っており、攻撃を継続することが不可能な状況で、甲はさらに乙を痛めつけようと乙に暴行を加えているから、防衛の意思の一個性も認められず、規範的にみて一個の行為と評価できない。

したがって、第2暴行は別個の行為とみるべきである。

そこで、以下、第1暴行、第2暴行それぞれについて検討を加える。

2 第1暴行について

(1) 死の結果は第1暴行に起因するものであるから、傷害致死罪の構成要件（205条）に該当する。

(2) もっとも、第1暴行には、正当防衛（36条1項）が成立すると考えてよい。

乙の攻撃は突然のものであって、甲の予測の範囲外のものであったと思われるし（「急迫不正の侵害」）、防衛行為に際して攻撃の意思が並存していたという事情も認められないから、防衛する意思（「防衛するため」）を肯定できる。

また、乙の金属バットによる攻撃に対して、甲は同人の胸を強く押したにとどまるのであるから、防衛行為の相当性（「やむを得ずにした行為」）も肯定できる。なお、生じた結果は死という重大なものであるが、正当防衛は不正の侵害に対する正の行為であるから、必ずしも厳格な法益の権衡は要求されない。

したがって、第1暴行は違法性が阻却され、犯罪が成立しない。

3 第2暴行について

(1) 一方で、第2暴行も、第1暴行によって生じた傷害を悪化させ、乙の死期を早める効果を有していたのだから、死との因果関係が認められ、傷害致死罪の構成要件に該当するとも考えられる。

しかし、このように解すると、構成要件レベルでは、死の結果の二重評価となってしまう妥当ではない。

本問では、第2暴行が第1暴行の追撃行為であり、その延長線上に位置づけられることを考慮すれば、死因を形成した第1暴行に死の結

果を帰責すべきである。

したがって、第2暴行は、傷害罪（204条）の構成要件に該当するに止まる。

(2) そして、第2暴行時には、上記のとおり侵害の継続も防衛の意思もなく、正当防衛は成立しない。

(3) 以上から、甲には傷害罪が成立する。

第2 現金とキャッシュカードを窃取した行為について

1 続いて、甲が現金とキャッシュカード（以下「現金等」という。）を窃取した行為は、乙の意思に反して現金等の占有を移転させているので、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗罪の客観的構成要件に該当する。なお、強盗罪（236条1項）の成立余地はない。強盗罪は暴行・脅迫を手段として他人から財物を強取することにその本質がある以上、暴行・脅迫時点において財物奪取の意思が必要だからである。

2 もっとも、甲の認識では、乙は既に死亡しており、死体から財物を奪取する意思しか有していない。

そこで、このような甲の誤認が故意（38条1項）の成否に影響を与えるのではないか。

故意とは、構成要件該当事実に対する認識・認容であり、窃盗罪の実行行為である「窃取」とは、占有者の意思に反して、他人の所有する財物を自己又は第三者の支配下に移すことである。

したがって、窃盗罪の故意が認められるためには、占有侵害の認識が必要である。

3

では、甲の認識した事実を基準として、乙が現金等を占有していた（その占有を侵奪した）といえるか。

確かに、死者自体には占有の事実も意思もなく、占有は認められない。しかし、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害していると評価できる場合には、なお刑法上の保護に値すると解する。

本問では、甲が現金等を奪ったのは、乙が気を失った直後であって、仮に乙が死亡していたとしても、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察すれば、なお乙の現金等に対する占有が認められる事案であるから、甲には占有侵害の認識がある。

したがって、窃盗罪の故意を認めることができる。

3 また、甲には、不法領得の意思に欠けるところもない。

以上から、甲には窃盗罪が成立する。

第3 罪数

以上から、甲には傷害罪、窃盗罪が成立し、これらは社会通念上別個の行為であるから、併合罪（45条前段）となる。

以 上

4